

1500299-33.2021.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas. Consta ainda que no dia 21 de agosto de 2021, às 22:30 horas, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1162, Tinga, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA, trazia consigo e guardava dentro da residência da sua genitora, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500299-33.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 19772647 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2574/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2228092 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA

Data da Audiência:

27/06/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 27 de junho de 2022, às 14 horas, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Alan Vargas Monteiro Ferreira e Anderson Fernando da Silva Neves. Ausente as testemunhas da defesa, a saber: Maria Estela Gonçalves, não intimada.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Alan Vargas Monteiro Ferreira e Anderson Fernando da Silva Neves, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos

por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha Maria Estela Gonçalves. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Homologo a desistência da Defesa quanto a oitiva da testemunha Maria Estela Gonçalves. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, absolvendo-se o réu da imputação capitulada no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006, mantendo-se no mais, os exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo o artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006, artigo 333 do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial em data incerta, porém, anteriormente ao dia 21 de agosto de 2021, o acusado e o adolescente L. F. F. dos S. (DN: 27/10/2003) se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas. Consta ainda que no dia 21 de agosto de 2021, às 22:30 horas, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1162, Tinga, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA, trazia consigo e guardava dentro da residência da sua genitora, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 383 (trezentos e oitenta e três) invólucros de cocaína, com peso de 358,04 gramas, e 15 (quinze) microtubos contendo maconha, com peso de 75,27 gramas. Também, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima descritas, LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Consta, por fim, que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 21 de agosto de 2021, LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA corrompeu o menor L. F. F. dos S. (DN: 27/10/2003 – dezessete anos de idade), com ele praticando as infrações anteriormente descritas. A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2021 (fls. 108/109). O réu foi citado (fl. 132) e apresentou resposta à acusação (fls. 137/138). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum, bem como foi realizado o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Encerrada a instrução criminal, na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A ação é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico e corrupção ativa. Senão vejamos. A materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição e apreensão (fl. 17), auto de constatação preliminar (fl. 18), laudos periciais (fls. 119/121 e 122/124) que confirmam a natureza das substâncias apreendidas e demais provas produzidas nos autos. A autoria delitiva, também, restou demonstrada e caracterizada nos autos. A testemunha e policial militar ALAN VARGAS MONTEIRO FERREIRA, na delegacia, disse que estava em patrulhamento pela Avenida Marechal Teodoro da Fonseca, Tinga, após ser irradiado via COPOM, que um veículo ford/fiesta/prata, com dois indivíduos estavam ostentando arma de fogo pela via, quando chegaram próximo ao número 1162, avistaram dois indivíduos e o veículo em um Bar denominado Bar do Mineiro, que após realizarem a abordagem dos dois, fora encontrada uma chave do veículo no bolso de Luiz Felipe, o veículo de placa DYF3C73 (FORD FIESTA/PRATA) estava estacionado logo a frente do BAR, assim sendo prosseguiram na revista do veículo, onde fora encontrado em baixo do banco do motorista, 15 porções de substância aparentando ser maconha, pesando 75,27g e 23 porções de substância aparentando ser cocaína embaladas a vaco, e R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) em dinheiro, armazenadas em um a bolsa amarela,

posteriormente ambos confessaram o crime de tráfico de drogas, e ofereceram aos policiais 10 mil reais em dinheiro para serem liberados, sendo que o Luiz Felipe Gonçalves da Gama, informou aos policiais onde estaria o restante dos entorpecentes, encaminhando a equipe até a residência da sua genitora, localizada na Rua Pica Pau, número 20, Jardim Gaivotas, chegando na residência a senhora Denise acompanhou as buscas, onde no quarto da residência, dentro do guarda roupa fora encontrado 360 porções de substâncias aparentando ser cocaína, totalizando 383 porções de substância aparentando ser cocaína, que pesam 358,04g. Diante dos fatos conduziu os autores juntamente com os objetos apreendidos para esta Delegacia de Polícia para a devida providência legal. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial militar ANDERSON FERNANDO DA SILVA NEVES, que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega. Em seu interrogatório policial o réu LUIZ FELIPE GONÇALVES GAMA, negou os fatos. Alegou que a droga apresentada pelos policiais militares não lhe pertencia, que nada de ilícito havia em seu carro e tão pouco em sua casa, que não possuía envolvimento com o tráfico de drogas. Esclarece que no momento da abordagem estava com seu colega de nome Luiz Felipe, em um bar, pois o combustível de seu carro havia acabado, e que estavam ali esperando sua irmã chegar para socorrer-los. Que os policiais chegaram e ordenaram que saíssem de dentro do bar, que pegaram as chaves de seu carro um Ford Fiesta, e revistaram o carro e que em seguida retornaram dizendo que haviam encontrado algumas porções de maconha e que lhe pediram a quantia de R\$ 11.000,00 para liberá-lo. Porém desconhece a procedência da droga. Indagado se possui passagem pela polícia, respondeu que sim, que possui três passagens por tráfico de drogas. Indagado pela Autoridade Policial se havia drogas de sua propriedade na casa de sua genitora, respondeu que não. Esclarece ainda que não reside com sua mãe, que reside no bairro do Morro do Algodão, e que não autorizou a entrada dos policiais militares na casa de sua mãe. Em Juízo, negou a prática do crime. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelos crimes de tráfico de drogas. Isto porque, as declarações dos policiais militares foram coesas desde a fase inquisitiva. Além disso, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a dinâmica da abordagem, o comportamento do acusado logo antes da apreensão, bem como a quantidade e variedade de drogas, demonstram a autoria delitiva. Em relação à corrupção ativa, os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo demonstram, com segurança, a autoria delitiva por parte do acusado. Inicialmente, rechaço a alegação de que o ingresso dos policiais na residência do investigado teria ocorrido sem observância do princípio da inviolabilidade de domicílio. Isto porque, os milicianos narraram que foram autorizados pela genitora do acusado a ingressar na residência, ainda, ressalto que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) . Ainda, trago à colação julgado do C. STJ que assim apreciou a validade de busca domiciliar em caso análogo: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)"(HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Afasto, de igual modo, a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular realizada. Sabe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça equipara a busca veicular à busca pessoal: "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022). Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista veicular em relação ao acusado, com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, ocorreu de modo regular, com espreque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo, a despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa. No caso sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da revista pessoal e veicular diante da inquestionável conduta suspeita do acusado, mormente em virtude das denúncias anônimas indicando prática delitiva recebidas pelos milicianos via COPOM. Nesse sentido: "TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. (...)" (STJ Habeas Corpus nº 552.395-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 20.02.2020); "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BUSCA VEICULAR EFETIVADA MEDIANTE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES QUE INDICAVAM A FUNDADA SUSPEITA PRECONIZADA NO ART. 240, § 2º, DO CPP. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 733.475/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Superado tal ponto, anoto que a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Cediço, ainda, que não há impedimento de que o usuário seja também traficante. Ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08). Quanto à prova oral, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Vejamos: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Ainda, vale ressaltar que eventuais pequenas incongruências nas declarações são compreensíveis dado o decurso do tempo entre a abordagem policial e a realização desta audiência, contudo não são capazes de retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares. Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). Observando-se o acervo probatório produzido, nota-se que a prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, indicando que o acusado trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção

da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018). E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator

(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021). Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre os réus. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe. No mesmo sentido, em relação ao delito previsto no artigo 333 do Código Penal, de rigor a absolvição do acusado. Com efeito, cediço que o C. STJ possui entendimento no sentido de que "cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação"(ut, Aglnt no

AREsp 1.247.259/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/5/2018). No caso em comento, não obstante os depoimentos prestados pelos policiais em solo policiais e em juízo, vislumbra-se que não constam dos autos quaisquer outros elementos que comprovem a prática criminosa imputada ao acusado, tais como imagens em vídeo, dinheiro em espécie ou testemunhas, logo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, destaco: "ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da vítima e relatos dos policiais. Desnecessária a apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante do roubo. Condenações mantidas. Penas reduzidas. No tocante ao crime de CORRUPÇÃO ATIVA, ausente demonstração inequívoca de oferecimento de vantagem indevida para a liberação da prisão em flagrante. Negativa do corréu DAVI que deve prevalecer em atenção ao princípio in dubio pro reo. Absolvição decretada. Parcial provimento aos recursos. (TJSP; Apelação Criminal 0002609-04.2017.8.26.0537; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022) Assim, a absolvição é medida que se impõe. No tocante ao delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), é de rigor a absolvição. Isto porque, a Lei nº 11.343/06 prevê causa especial de aumento de pena caso o crime de tráfico envolva ou atinja criança ou adolescente, conforme previsão do artigo 40, inciso VI, do referido diploma legal, in verbis: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação"; Assim, para evitar a ocorrência de bis in idem, de rigor a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista na Lei de Drogas e a absolvição do delito previsto no artigo 244-B do ECA, em homenagem ao princípio da especialidade. Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes praticado na companhia de adolescente (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em concurso material - Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da absorção do delito de corrupção de menores pelo de tráfico de drogas - Autoria e materialidade bem demonstradas, com a venda de entorpecentes a um usuário tendo sido presenciada pelos policiais militares responsáveis pela prisão - Sentenciado que trazia consigo e guardava, na companhia do adolescente mencionado na denúncia, 54 porções de "cocaína" com peso líquido total de 59,23g - Reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas e do delito previsto no ECA que caracteriza inegável "bis in idem" - Majorante prevista na Lei Antidrogas que é "norma especial" em relação à corrupção de menores, por se referir à prática, na companhia do(s) menor(es), de delito específico - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nºs 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acórdão - Recurso parcialmente provido para absolver o sentenciado quanto à acusação de prática do delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantida a condenação pelo delito do art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. (TJSP; Apelação Criminal 1500510-12.2019.8.26.0603; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021, destaquei); "RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo crime de tráfico de drogas com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. 2. Não é cabível a condenação por

tráfico com aumento de pena e a condenação por corrupção de menores, uma vez que o agente estaria sendo punido duplamente por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in idem). 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. In casu, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei. 5. Recurso especial improvido (RECURSO ESPECIAL Nº 1.622.781 - MT, Relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª Turma, j. em 22/11/2016); "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura bis in idem a condenação conjunta do tráfico de drogas majorado pela participação de menor com o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. Agravo regimental desprovido". (AgRg nos EDcl no REsp 1716826/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018). Assim, tendo em vista a prova produzida e os argumentos apresentados, é de rigor a parcial procedência da ação nos termos acima delineados. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 53/58), assim, elevo as penas em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Tendo em vista que o acusado é reincidente, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/06, em relação ao delito de tráfico de drogas, conforme acima fundamentado. Assim, elevo a pena deste delito em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;. Por fim, em razão do concurso material, fixo a pena final em 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão, além de 792 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime FECHADO para o cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, qual seja, a mercancia de grande quantidade e variedade de entorpecentes, envolvendo a participação de adolescente. Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Não preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu LUIZ FELIPE GONÇALVES DA GAMA à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 680 dias-multa dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06. ABSOLVO o acusado no tocante à imputação de prática dos delitos do art. 333 do CP, do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, com esteio no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Recomende-se ao local em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisória. DECRETO o

perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas – Funad. VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados”. NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EvNed-LA0LtHpq4CfNRSM5oBAvVI14Ate5mb73e-wBxMhQ?e=apanan